上訴與救濟 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：上訴期間與程式要件、上訴審級與範圍（二審、三審）、想像競合上訴、抗告與再抗告、再審、簡易判決上訴救濟、回復原狀、非常上訴
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含113年）
> 題數：共 21 題

壹、上訴期間與程式要件（送達、期間計算、合法上訴）

1、111年第42題（原第42題）

> 甲因竊盜案經法院審理後判處有期徒刑一年，法院宣判後，甲因另案於 3 月 1 日入獄服刑，法院知悉後將判決書分別於： 3 月 5 日送達甲之住所，由甲之同居父親簽收； 3 月 6 日囑託甲服刑之監獄長官送達甲簽收； 3 月 7 日送達甲指定之送達代收人律師乙簽收。如甲不服判決，至遲須在何日前提起上訴？

(A) 3月25日
(B) 3月26日
(C) 3月27日
(D) 3月29日

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	若以3月5日住所送達起算20日，期滿日為3月25日。惟甲已入獄服刑，住所送達由同居父親簽收雖屬補充送達，但法院知悉甲在監，依法應囑託監獄長官送達本人，以3月5日起算並不正確。
(B)	✓	甲已在監服刑，法院知悉後依刑訴§56準用民訴送達規定，應囑託監獄長官送達。**3月6日囑託監獄長官送達甲本人簽收**，為對甲本人之合法送達。上訴期間為**20日**（刑訴§349 I），自3月6日之翌日（3月7日）起算20日，期滿日為**3月26日**。甲至遲須於3月26日前提起上訴。
(C)	✗	若以3月7日送達代收人律師乙起算20日，為3月27日。惟送達效力以最先合法送達為準，3月6日囑託送達已先生效。
(D)	✗	計算錯誤。無論以何日起算，均不會得出3月29日之結果。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 在監被告之送達，法院知悉後應**囑託監獄長官送達本人**（刑訴§56準用民訴規定）。
> - 上訴期間為判決送達後**20日**內（刑訴§349 I）。
> - 有多次送達時，以**最先合法送達**之日起算上訴期間。
> - 期間之計算：始日不算入（刑訴§65 I），自送達翌日起算。

2、112年第50題（原第50題）

> 被告之住居所因不在法院所在地，乃向法院陳明以律師甲為送達代收人，法院嗣向甲送達判決書。被告提起上訴之期間，應自何時起算及是否應扣除在途期間？

(A) 自該判決書送達予甲後起算，不用扣除在途期間
(B) 自該判決書送達予甲後起算，應扣除在途期間
(C) 自甲實際轉交該判決書予被告之日起算，不用扣除在途期間
(D) 自甲實際轉交該判決書予被告之日起算，應扣除在途期間

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	送達予送達代收人時即生送達效力，此部分正確。但被告住居所不在法院所在地，依刑訴§66，**應扣除在途期間**。
(B)	✓	依刑訴§62準用民訴§137，向送達代收人為送達者，**於送達予代收人時即生送達效力**，無須待代收人實際轉交被告。上訴期間自送達予甲之翌日起算。又被告住居所不在法院所在地，依刑訴§66規定，**應扣除在途期間**，以保障被告之上訴權。
(C)	✗	送達效力自送達代收人時即生，不以實際轉交為生效時點。
(D)	✗	起算日錯誤，同(C)之說明。

[!NOTE]
重點整理

- 送達代收人收受送達時，即生**送達效力**，不以實際轉交當事人為生效要件。
- 被告住居所不在法院所在地者，上訴期間應**扣除在途期間**（刑訴§66）。
- 在途期間依司法院所定標準計算，目的在保障遠地當事人之訴訟權。

3、109年第58題（原第58題）

有關不服地方法院第一審判決提起上訴，其上訴理由記載是否合法，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 不服第一審通常程序判決，上訴第二審時，上訴書狀僅記載「量刑過重」，為合法上訴
(B) 第一審判處死刑，被告上訴第二審時，其上訴書狀僅記載「量刑過重」，為合法上訴
(C) 不服第一審通常程序判決，上訴第二審時，如上訴書狀未敘述上訴理由，法院得直接判決駁回
(D) 不服第一審簡易判決，上訴第二審時，上訴書狀應記載具體理由，否則上訴不合法

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	不服第一審通常程序判決上訴第二審，依刑訴§361 II，上訴書狀應敘述**具體理由**。僅記載「量刑過重」而未具體說明原審量刑如何違法或不當，屬不具體之上訴理由，上訴不合法。
(B)	✗	依刑訴§344 V，宣告死刑之案件，法院應依職權逕送上訴，無待被告提起。但若被告自行上訴，仍應符合上訴書狀敘述具體理由之要求。僅記載「量刑過重」仍非具體理由。
(C)	✗	上訴書狀未敘述上訴理由，法院應先定期間命補正（刑訴§361 III），**不得直接判決駁回**。經定期補正逾期未補正者，始得以裁定駁回上訴。
(D)	✓	依刑訴§455-1 III，不服簡易判決上訴第二審（管轄之地方法院合議庭），**準用第三審上訴之規定**（刑訴§382 I），上訴書狀應記載**具體理由**並指摘原判決違背法令之處。未記載具體理由者，上訴不合法。

[!NOTE]
重點整理

- 通常程序上訴二審：須敘述**具體理由**（刑訴§361 II）；未敘述者，法院應先命**補正**（§361 III）。
- 簡易判決上訴二審：準用第三審上訴規定（刑訴§455-1 III），須記載具體理由，否則上訴不合法。
- 宣告死刑或無期徒刑之案件，法院應**依職權逕送上訴**（刑訴§344 V）。

4、111年第50題（原第50題）

原審之辯護人收受判決正本，與被告討論後，經被告授意提起上訴。該辯護人應以何人之名義提起上訴，始為合法？

(A) 以被告之名義提起上訴。因原審辯護人之上訴，性質上為代理上訴
(B) 以辯護人之名義提起上訴。因原審之辯護人得為被告之利益而上訴
(C) 以被告之名義提起上訴。因原審之辯護人得為被告之利益而獨立上訴
(D) 以辯護人或被告之名義提起上訴均可。因原審之辯護人得為被告之利益而上訴，被告則為有上訴權之當事人

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	依刑訴§346，原審之**代理人或辯護人**得為被告之利益而上訴，但**非獨立上訴權**。辯護人為被告之利益上訴，係**代理上訴**，應以**被告名義**提起上訴。辯護人經被告授意提起上訴，更顯示代理性質，應以被告名義為之。
(B)	✗	辯護人雖依§346得為被告利益上訴，但此非獨立上訴權，不得以辯護人自己名義提起。以辯護人名義提起上訴，不合法。
(C)	✗	以被告名義上訴為正確，但理由有誤。辯護人之上訴並非「獨立上訴」，而係**代理上訴**。獨立上訴係指被告之法定代理人或配偶等依§345規定所為之上訴，不待被告授意。
(D)	✗	不得以辯護人名義提起上訴。辯護人上訴之性質為代理被告上訴，須以被告名義為之。

[!NOTE]
重點整理

- 辯護人依刑訴§346得為被告利益上訴，性質為**代理上訴**，應以**被告名義**提起。
- **獨立上訴**（刑訴§345）：被告之法定代理人或配偶得**獨立**為被告利益上訴，不待被告授意。
- 代理上訴 vs 獨立上訴之區分：辯護人→代理上訴（被告名義）；法定代理人、配偶→獨立上訴（得以自己名義）。

5、111年第60題（原第60題）

下列關於第二審上訴之敘述，何者正確？

(A) 提起第二審上訴，應由第一審法院先為審查。第一審法院如認上訴已逾上訴期間，應以判決駁回
(B) 提起第二審上訴，應由第一審法院先為審查。第一審法院如認上訴書狀未敘述具體理由，應逕以裁定駁回
(C) 原審之辯護人得為被告之利益提起上訴，故上訴狀得以辯護人自己之名義提起上訴
(D) 被告於第一審判決後死亡，配偶已失其獨立上訴權，不得再以自己之名義提起上訴

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	第一審法院如認上訴逾期，應以**裁定**駁回（刑訴§362），非以判決駁回。判決與裁定之區分為重要程序概念。
(B)	✗	上訴書狀未敘述具體理由，第一審法院應先**定期間命補正**（刑訴§361 III），不得逕以裁定駁回。經定期補正逾期仍未補正者，始得裁定駁回。
(C)	✗	辯護人依§346為被告利益上訴，係代理上訴，應以**被告名義**提起，不得以辯護人自己名義提起。
(D)	✓	依刑訴§345，配偶之獨立上訴權係為被告之利益而設。被告於第一審判決後**死亡**，依刑訴§303④應諭知不受理判決，訴訟程序因被告死亡而終結。配偶已**失其獨立上訴權**，不得再以自己名義提起上訴。被告死亡後，刑罰權已無行使之對象，上訴已無實益。

[!NOTE]
重點整理

- 第一審法院審查上訴逾期→以**裁定**駁回（刑訴§362），非以判決駁回。
- 上訴書狀未敘述具體理由→先命**補正**，逾期未補正始得裁定駁回。
- 辯護人上訴→以被告名義（代理上訴）；配偶/法定代理人→獨立上訴（以自己名義）。
- 被告死亡→配偶失獨立上訴權。

貳、上訴審級與範圍（二審、三審審查範圍、想像競合上訴）

6、111年第51題（原第51題）

檢察官以被告犯過失重傷害罪提起公訴，第一審法院以告訴人告訴逾越告訴期間為由，諭知公訴不受理，在上訴期間，被害人因同一原因事由死亡。檢察官於上訴期間屆滿前提起上訴，第二審法院審理後之處理，下列敘述何者最為正確？

(A) 自為判決。過失重傷害與過失致死係同一案件，第二審法院係事實審，自得變更罪名而為判決
(B) 自為判決。過失重傷害雖屬告訴乃論之罪，但過失致死係非告訴乃論之罪，無告訴逾期之問題
(C) 撤銷發回原審。過失重傷害與過失致死事實不同，非同一案件，第二審法院顯就未受請求事項而予判決

(D) 撤銷發回原審。因係同一案件，得撤銷第一審判決，將案件發回原審法院，以維被告審級利益

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	過失重傷害與過失致死雖屬同一案件（基本社會事實同一），但第一審僅為程序判決（公訴不受理），未進入實體審理。第二審若自為實體判決，將剝奪被告於第一審之**審級利益**，與審級制度之保障不符。
(B)	✗	結論方向正確（過失致死為非告訴乃論之罪，無告訴逾期問題），但處理方式錯誤。第二審不應自為判決，應發回第一審。
(C)	✗	過失重傷害與過失致死之基本社會事實同一（同一過失行為、同一被害人），屬同一案件，非不同事實。
(D)	✓	過失重傷害與過失致死係**同一案件**（基本社會事實同一）。被害人於上訴期間死亡，案件事實由過失重傷害變更為過失致死（非告訴乃論之罪）。第一審僅為程序判決（不受理），第二審認為第一審判決有誤時，應**撤銷發回原審**（刑訴§369 I），使案件回到第一審進行實體審理，以維被告之**審級利益**。

[!NOTE]
重點整理

- 過失重傷害→被害人死亡→過失致死：**屬同一案件**（基本社會事實同一），法院得變更起訴法條。
- 過失重傷害為告訴乃論之罪，過失致死為**非告訴乃論之罪**，無告訴逾期問題。
- 第一審僅為程序判決時，第二審應**撤銷發回**而非自為實體判決，以保障被告之**審級利益**。

7、111年第52題（原第52題）

檢察官起訴甲想像競合犯竊盜、行使偽造私文書、詐欺取財罪嫌，第一審法院認為竊盜不成立，另兩罪成立，故從一重論以行使偽造私文書罪，竊盜不另為無罪諭知，檢察官不服上訴，第二審法院認三罪均成立，撤銷改判，仍從一重論以行使偽造私文書罪。上述三罪，何者為得上訴第三審之罪名？

(A) 僅行使偽造私文書罪
(B) 行使偽造私文書、詐欺取財二罪
(C) 行使偽造私文書、竊盜二罪
(D) 行使偽造私文書、詐欺取財、竊盜三罪

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	僅列最重罪名，忽略竊盜部分。竊盜罪經第一審不另為無罪諭知，第二審改認成立，對被告產生不利益變動，應許上訴第三審。
(B)	✗	詐欺取財罪為刑訴§376 I所列之案件（最重本刑3年以下），一、二審均判有罪，**不得上訴第三審**。
(C)	✓	**行使偽造私文書罪**：非§376案件，得上訴第三審。**竊盜罪**：雖為§376案件，但第一審不另為無罪諭知（實質上為無罪），第二審改認成立（等同於二審始受有罪判決），依§376 I但書，屬「第一審無罪→第二審改判有罪」之情形，得上訴第三審。**詐欺取財罪**：§376案件，一、二審均認成立，不得上訴第三審。故得上訴第三審者為行使偽造私文書及竊盜二罪。
(D)	✗	詐欺取財罪一、二審均認有罪，屬§376案件，不得上訴第三審。三罪全部得上訴之說法有誤。

[!NOTE]
重點整理

- 想像競合犯之上訴：各罪名分別判斷是否得上訴第三審，**非僅以最重罪名判斷**。
- §376 I「不得上訴第三審」之例外（但書）：第一審無罪（含不另為無罪諭知），**第二審改判有罪**者，得上訴第三審。
- 「不另為無罪諭知」在上訴審級判斷上，實質等同於無罪判決。

8、110年第59題（原第59題）

> 甲因涉犯偽造有價證券罪嫌及行使偽造私文書罪嫌，經檢察官依想像競合犯之關係，提起公訴。第一審法院審理結果，認定甲僅成立偽造有價證券罪，理由內就行使偽造私文書罪嫌部分，說明因不能證明犯罪，而不另為無罪之諭知。甲及檢察官均提起上訴，第二審法院審理結果，撤銷第一審判決，惟僅就有罪部分改依刑法第59條規定減輕其刑，仍認定僅成立偽造有價證券罪，並於理由內就行使偽造私文書罪嫌部分，說明不另為無罪之諭知。僅甲不服提起第三審上訴。關於第三審審理範圍之敘述，依實務見解，下列何者最為正確？

(A) 僅能審理偽造有價證券罪嫌部分；行使偽造私文書罪嫌已確定，第三審不得審理
(B) 偽造有價證券及行使偽造私文書罪嫌全部，第三審均得為審理
(C) 偽造有價證券及行使偽造私文書罪嫌全部發生移審效果，但第三審不得審理行使偽造私文書罪嫌部分
(D) 僅能審理偽造有價證券罪嫌部分；但檢察官於第三審判決前倘有爭執，則例外及於行使偽造私文書罪嫌部分

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	行使偽造私文書罪為刑訴§376案件，一、二審均不另為無罪諭知（實質上均為無罪認定，對被告並無不利益變動），不符合§376但書之例外情形，故行使偽造私文書罪嫌部分**已確定**，不隨偽造有價證券罪移審至第三審。第三審**僅能審理偽造有價證券罪嫌部分**。
(B)	✗	行使偽造私文書罪嫌部分已確定，第三審不得審理全部。
(C)	✗	行使偽造私文書罪嫌部分未發生移審效果，因該部分已確定。
(D)	✗	已確定部分不因檢察官之爭執而例外移審。僅甲上訴，檢察官未上訴，檢察官於第三審無從主張。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 想像競合犯各罪名之上訴三審，**分別判斷**是否得上訴。
> - §376案件之「不另為無罪諭知」，一、二審均維持無罪認定者，不符合§376但書例外，該部分已**確定**，不隨主罪移審至第三審。
> - 第三審之審理範圍以得合法上訴之部分為限。

9、112年第48題（原第48題）

> 被告以原審鑑定人不具備鑑定資格為理由上訴至第三審，第三審法院得否就鑑定人之資格進行調查事實？

(A) 不可以。被告不得以鑑定人不具備鑑定資格為理由上訴至第三審，第三審法院自然不應為調查事實
(B) 不可以。第三審法院應以第二審判決認定之事實為限，法院不得再依職權調查事實
(C) 可以。不論被告是否指摘鑑定人資格不備，第三審法院均應依職權調查事實
(D) 可以。鑑定人不具備鑑定資格屬於上訴理由所指摘之事項，且本質上屬於訴訟程序之事項，第三審法院得調查事實

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	鑑定人資格不備屬於**訴訟程序違法**之事項，被告得以此為由主張原判決違背法令而上訴第三審。§379可能構成判決當然違背法令之情形。
(B)	✗	第三審為法律審，原則上以第二審認定之事實為判斷基礎，不得為事實之調查。但此原則有例外，就**訴訟程序之事項**，第三審得自行調查（刑訴§393）。
(C)	✗	第三審就訴訟程序事項之調查，仍以上訴理由所指摘之事項為範圍，並非不論被告是否指摘均應依職權調查。
(D)	✓	依刑訴§393，第三審法院就「關於訴訟程序」之事項，得自行**調查事實**。鑑定人是否具備鑑定資格，本質上屬於**訴訟程序**之事項（證據調查程序是否合法），非屬犯罪事實之認定。被告以此為上訴理由指摘，第三審法院得就該訴訟程序事項自行調查事實。

[!NOTE]
重點整理

- 第三審為**法律審**，原則上不得調查事實，以第二審認定之事實為基礎。
- 例外：就**訴訟程序之事項**，第三審得自行調查事實（刑訴§393）。
- 鑑定人資格屬訴訟程序事項，非犯罪事實之認定。
- 第三審上訴須指摘原判決**違背法令**（刑訴§377）。

10、111年第59題（原第59題）

A涉犯背信罪，獲不法利益100萬元。一審法院判決A有罪，惟漏未就A犯罪所得諭知沒收。檢察官與 A 均上訴二審，雙方未指摘漏未沒收部分，但二審法院調查後，認為一審漏未沒收部分違法，無可維持，予以撤銷改判，判決 A 有罪，並諭知沒收 100 萬元。背信罪屬刑事訴訟法第 376 條第 1 項第5款罪名，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 二審沒收判決是初次不利益判決，A得就二審沒收部分上訴第三審法院
(B) A不得對二審判決有罪部分上訴第三審法院
(C) 檢察官不得對二審判決上訴第三審法院
(D) 如果一審諭知無罪，二審改判有罪，檢察官得為A上訴第三審法院

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	**本選項為錯誤敘述（即本題答案）**。背信罪為§376 I⑤案件，一、二審均判A有罪，依§376不得上訴第三審。沒收雖為二審始諭知，但沒收具有**從屬性**，依附於本案罪刑。本案罪刑部分既不得上訴第三審，沒收部分亦不得獨立上訴第三審。A不得就沒收部分上訴。
(B)	✓	背信罪為§376案件，一、二審均有罪，A不得對有罪部分上訴第三審。正確。
(C)	✓	同理，檢察官亦不得對§376案件之二審判決上訴第三審。正確。
(D)	✓	依§376 I但書，一審無罪→二審改判有罪者，得上訴第三審。檢察官依§344 IV得為被告利益上訴。正確。

[!NOTE]
重點整理

- §376案件：一、二審均有罪者，不得上訴第三審。
- **沒收之從屬性**：沒收依附於本案罪刑，本案不得上訴第三審者，沒收亦不得獨立上訴第三審。
- §376但書例外：一審無罪→二審改判有罪者，得上訴第三審（保障被告之審級利益）。
- 檢察官得為被告利益上訴（刑訴§344 IV）。

11、108年第59題（原第59題）

某甲犯殺人罪，依法減刑後，其判決主文宣告「處無期徒刑，褫奪公權終身，減為有期徒刑20年，褫奪公權10年」，被告未上訴。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 因宣告無期徒刑，故法院應依職權逕送上訴
(B) 因宣告已減為有期徒刑，故法院無庸依職權送上訴
(C) 因殺人罪法定刑有死刑、無期徒刑，故法院應依職權逕送上訴
(D) 因該殺人罪依法減刑後，法定刑及宣告刑最重為有期徒刑，故法院無庸依職權送上訴

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	依刑訴§344 V，宣告**死刑或無期徒刑**之案件，原審法院應不待上訴，依職權逕送該管上級法院審判。甲之判決主文**宣告無期徒刑**後始予減刑，其「宣告刑」仍為無期徒刑（減刑係就宣告刑執行減輕），故法院應依職權逕送上訴。

(B) ✗ 雖減刑後執行刑為有期徒刑20年，但「宣告刑」為無期徒刑，仍符合§344 V依職權逕送上訴之要件。判斷基準在於**宣告刑**，非減刑後刑度。

(C) ✗ 判斷依據非法定刑，而係**宣告刑**。即使法定刑有死刑或無期徒刑，若宣告刑為有期徒刑，未必須依職權送上訴。本題宣告刑確為無期徒刑，但理由應以宣告刑為據。

(D) ✗ 減刑後法定刑及宣告刑最重為有期徒刑之說法錯誤。宣告刑為無期徒刑，減刑僅係就已宣告之無期徒刑予以減輕。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 依職權逕送上訴（刑訴§344 V）：宣告**死刑或無期徒刑**者，法院應依職權逕送上級法院。
> - 判斷基準為**宣告刑**，非法定刑，亦非減刑後之執行刑。
> - 減刑係就宣告刑減輕，不改變原宣告刑之性質。

12、112年第60題（原第60題）

> 下列關於第一審訴訟程序瑕疵，得否於第二審補正之敘述，依實務見解，何者最為正確？

(A) 第一審未告以有關書證之要旨使上訴人有申辯之機會，此項瑕疵得因第二審補行提示而獲治癒
(B) 第一審漏未提示物證，此項瑕疵不得因第二審補行提示而獲治癒
(C) 應行合議審判案件，第一審雖誤由受命法官獨任判決，但得因第二審已行合議審判而獲治癒
(D) 法院就檢察官起訴之本案並無管轄權，得因檢察官於第二審追加起訴有管轄權之相牽連案件而獲補正

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	依實務見解，第一審證據調查程序之瑕疵（如未告以書證要旨），**得因第二審補行適法之證據調查程序而治癒**。第二審為事實審，覆審制下得就全部案件重新調查，補行提示書證並告以要旨後，第一審之程序瑕疵即獲治癒。
(B)	✗	第一審漏未提示物證，與漏未告以書證要旨同屬證據調查程序瑕疵，**得因第二審補行提示而治癒**，非不得補正。
(C)	✗	應行合議審判而誤由獨任法官判決，**屬法院組織違法**，為判決當然違背法令（刑訴§379①），性質上**不得因第二審已行合議審判而補正**。第二審應撤銷第一審判決。
(D)	✗	法院無管轄權，屬**管轄錯誤**，不得因第二審追加起訴相牽連案件而獲補正。管轄之有無依起訴時定之。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 第一審**證據調查程序**瑕疵（如未告以書證要旨、漏未提示物證），得於**第二審補正**治癒。
> - 第一審**法院組織違法**（獨任審判應行合議之案件）→判決當然違背法令，**不得補正**。
> - 管轄錯誤**不得**以第二審追加起訴補正。

參、抗告與再抗告

13、108年第60題（原第60題）

> 某甲提起自訴，經第一審法院裁定駁回自訴，甲不服提出抗告，經抗告法院駁回後，提出再抗告。關於再抗告合法性之敘述，何者正確？

(A) 合法。為保障訴訟權，刑事訴訟法規定原則上皆應容許被告提出再抗告
(B) 合法。甲之抗告遭駁回後，性質上等同於駁回上訴之裁定，應容許提出再抗告
(C) 不合法。針對駁回自訴之裁定，不得提出抗告，亦不得提出再抗告
(D) 不合法。再抗告以法律有明文規定者為限，甲之情況非屬法律列舉得再抗告事由

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	再抗告並非原則上均得提出。依刑訴§415 I，再抗告**以法律有明文規定者為限**，非原則上容許。且本題甲為自訴人，非被告。
(B)	✗	抗告法院駁回抗告之裁定，不等同於駁回上訴之裁定，兩者性質不同。再抗告之容許性須依法律明文，不得類推。
(C)	✗	駁回自訴之裁定**得提出抗告**（刑訴§403），故前半段錯誤。駁回自訴係影響當事人訴訟權之重要裁定，依法得抗告。
(D)	✓	依刑訴§415 I，再抗告**以法律有特別規定者為限**。駁回自訴之裁定經抗告駁回後，法律並無明文規定得再抗告，故甲之再抗告不合法。再抗告之容許性採**法定主義**，僅於法律明文列舉之事由始得為之。

[!NOTE]
重點整理

- **抗告**：對法院之裁定不服，原則上得抗告（刑訴§403），但有不得抗告之例外。
- **再抗告**：以**法律有特別規定者為限**（刑訴§415 I），採法定主義，非一般性容許。
- 駁回自訴之裁定→得抗告→抗告被駁回→無法律明文容許再抗告→再抗告不合法。

14、109年第59題（原第59題）

當事人不服法院駁回其關於調查證據之聲請，應如何請求救濟，下列敘述何者正確？

(A) 向直接上級法院提起抗告。因法院駁回調查證據之聲請，必須作成裁定，當事人不服法院之裁定，得抗告於直接上級法院
(B) 向原審法院聲明異議。因法院駁回調查證據之聲請，屬於審判長或受命法官有關調查證據之處分，當事人不服，得向原審法院聲明異議
(C) 向直接上級法院提起抗告或上訴均可。因法院駁回調查證據之聲請，必須作成裁定，當事人不服法院之裁定，得抗告於直接上級法院；如當事人未提起抗告，則得於提起上訴時主張
(D) 法院駁回調查證據之聲請，屬於判決前關於訴訟程序之裁定，當事人不得聲明不服，僅能於上訴時主張

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	駁回調查證據之聲請雖以裁定為之，但依刑訴§404但書，**判決前關於訴訟程序之裁定，不得抗告**。當事人不得逕向上級法院提起抗告。
(B)	✗	聲明異議（刑訴§288-3）係針對審判長或受命法官關於**證據調查或訴訟指揮**之處分。但法院以裁定駁回調查證據之聲請，並非審判長個人之訴訟指揮處分，而係法院（合議庭）之裁定，不得以聲明異議救濟。
(C)	✗	如前述，不得抗告。「得於上訴時主張」部分正確，但選項整體錯誤。
(D)	✓	法院駁回調查證據之聲請，**屬判決前關於訴訟程序之裁定**（刑訴§404但書），當事人**不得聲明不服**。救濟途徑為：於不服判決而**提起上訴時**，以法院未調查有利證據為上訴理由，主張原審判決有「應調查之證據未予調查」之違法（刑訴§379⑩）。

[!NOTE]
重點整理

- 駁回調查證據聲請之裁定 = **判決前關於訴訟程序之裁定→不得抗告**（刑訴§404但書）。
- 救濟方式：於**上訴時**主張原審有「應調查之證據未予調查」之違法。
- 聲明異議（§288-3）對象為審判長/受命法官之訴訟指揮處分，非法院之裁定。
- 不得抗告 ≠ 不得救濟，仍可透過上訴主張。

肆、再審

15、111年第58題（原第58題）

檢察官有客觀注意義務，不僅指通常審判程序中有之，即便在開始再審後之審判程序亦然，故當二審檢察官為在監的死刑犯受刑人之利益聲請再審，下列敘述何者最為正確？

(A) 檢察官將聲請書遞交法院後，就可以直接釋放在監受刑人
(B) 法官裁定開始再審後，檢察官為節省訴訟程序可以直接撤回本件之起訴
(C) 法官裁定開始再審後，檢察官不得請求法院為無罪判決，只能請求從輕判決
(D) 法官裁定開始再審後，得裁定停止刑罰之執行

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	聲請再審並不當然停止刑罰之執行（刑訴§430）。檢察官遞交聲請書後，法院尚未裁定是否開始再審，不得直接釋放在監受刑人。
(B)	✗	再審開始後，案件回復至判決前之程序狀態（刑訴§436），應**依判決前之程序更為審判**。檢察官不得直接撤回起訴，因再審程序之目的在重新審理案件。
(C)	✗	檢察官有**客觀注意義務**（刑訴§2 I），應就有利不利被告之情形一律注意。再審開始後，檢察官若認被告確屬無辜，自得請求法院為**無罪判決**，不限於請求從輕判決。
(D)	✓	依刑訴§435 II，法院為**開始再審之裁定**後，**得以裁定停止刑罰之執行**。此規定之目的在於避免受刑人於再審程序進行中仍持續執行可能錯誤之刑罰，尤其對死刑犯更為重要。

[!NOTE]
重點整理

- 聲請再審**不停止刑罰之執行**（刑訴§430）；但法院裁定**開始再審**後，**得裁定停止刑罰之執行**（§435 II）。
- 再審開始後，回復至判決前程序狀態，**依判決前之程序更為審判**（§436）。
- 檢察官之**客觀注意義務**貫穿通常程序與再審程序，得請求無罪判決。

16、114年第59題（原第59題）

甲涉犯普通竊盜及強制罪嫌之裁判上一罪，經檢察官向臺灣臺北地方法院提起公訴。臺灣臺北地方法院審理結果，就甲被訴強制罪嫌部分判決有罪，被訴普通竊盜罪嫌部分，則於判決理由內說明不另為無罪之諭知。檢察官及甲均不服提起上訴，臺灣高等法院審理結果，認定檢察官之上訴有理由，甲之上訴則無理由，因而撤銷第一審判決，改依想像競合犯之規定，從一重論處甲犯普通竊盜罪刑確定。甲不服欲向法院聲請再審，關於聲請再審程序之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 甲聲請再審，應向臺灣臺北地方法院提起
(B) 甲聲請再審倘經裁定駁回，對於普通竊盜罪部分，得提起抗告，對於強制罪部分，不得提起抗告
(C) 甲聲請再審倘經裁定駁回，對於普通竊盜罪及強制罪部分，均不得提起抗告
(D) 甲聲請再審倘經裁定駁回，對於普通竊盜罪及強制罪部分，均得提起抗告

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	依刑訴§426 I，再審應向**為原確定判決之法院**聲請。本案確定判決為**臺灣高等法院**第二審判決，故應向臺灣高等法院聲請再審，非向臺灣臺北地方法院。
(B)	✗	普通竊盜與強制罪為想像競合之裁判上一罪，屬**一個判決**，聲請再審倘經駁回，其抗告不應區分各罪名分別處理。
(C)	✗	駁回再審聲請之裁定，依刑訴§411但書①，**得提起抗告**。無論普通竊盜或強制罪部分，均得抗告。
(D)	✓	普通竊盜與強制罪屬想像競合之**裁判上一罪**，為一個判決之整體。二審判決改從一重論處普通竊盜罪刑，甲應向**臺灣高等法院**聲請再審。聲請再審倘經裁定駁回，依刑訴§411但書①，**均得提起抗告**。想像競合之各罪名為不可分割之整體，抗告之效力及於全部。

[!NOTE]
重點整理

- 再審應向**為原確定判決之法院**聲請（刑訴§426 I）。
- 駁回再審聲請之裁定，依法**得抗告**（刑訴§411但書①）。
- 想像競合之裁判上一罪，屬不可分割之整體，再審與抗告之效力及於全部罪名。

17、109年第60題（原第60題）

> 檢察官起訴被告涉犯傷害罪嫌，第一審判決被告無罪，檢察官提起上訴，第二審法院誤檢察官上訴逾期，以不合法程序駁回上訴判決確定，依現行實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 此為程序判決，不生實質確定力，第二審可逕對合法上訴進行審判
(B) 此為程序判決，僅生形式確定力，不得提起非常上訴
(C) 應依再審程序將該確定判決撤銷後，始能就合法上訴部分進行審判
(D) 應依非常上訴程序將該確定判決撤銷後，始能就合法上訴部分進行審判

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	雖為程序判決（駁回上訴），但判決一旦確定，即生確定力。第二審法院不得逕行重新審理，須先透過救濟程序撤銷確定判決。
(B)	✗	該判決生形式確定力，但並非不得救濟。依實務見解，得以**再審**程序救濟。另非常上訴以判決確定後發現違背法令為要件，是否得提起非常上訴，與本題所問之救濟途徑不同。
(C)	✓	依實務見解（最高法院相關判例），第二審法院**誤認上訴逾期而駁回上訴**之確定判決，屬**事實認定錯誤**（誤認送達日、上訴期間等事實），得依**再審程序**撤銷。透過再審撤銷該確定判決後，始能就原來之合法上訴重新進行審判。此與非常上訴（針對法律適用錯誤）不同。
(D)	✗	非常上訴係針對判決**違背法令**之救濟（刑訴§441）。本件第二審法院係因**事實認定錯誤**（誤認上訴是否逾期），而非法律適用錯誤。依實務見解，應以**再審**而非非常上訴為救濟途徑。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 二審誤認上訴逾期而駁回 = **事實認定錯誤**→以**再審**救濟。
> - 非常上訴 = 判決確定後發現**違背法令**→由**檢察總長**向最高法院提起。
> - 再審 vs 非常上訴之區分：事實錯誤→再審；法令違背→非常上訴。
> - 確定判決一旦生確定力，須透過法定救濟程序撤銷，不得逕行重新審判。

伍、簡易判決之上訴救濟

18、111年第49題（原第49題）

> 檢察官依通常程序起訴被告搶奪罪，經法院訊問後被告自白犯罪，法院認為宜以簡易判決處刑，最終處有期徒刑兩年，緩刑五年。檢察官不服，上訴至管轄之第二審地方法院合議庭，地方法院合議庭認為上訴無理由，駁回上訴。依實務見解，檢察官此時得否再對第二審判決上訴？

(A) 可以。搶奪罪非屬刑事訴訟法第376條之案件，檢察官自得針對二審判決上訴第三審，此時應向高等法院提起第三審上訴
(B) 可以。搶奪罪非屬刑事訴訟法第376條之案件，檢察官自得針對二審判決上訴第三審，此時應向最高法院提起第三審上訴
(C) 不可以。簡易處刑判決，僅被告得上訴第三審，不容許檢察官上訴第三審
(D) 不可以。簡易程序僅有一次救濟機會，此時檢察官不得上訴第三審

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	簡易判決之上訴體系有別於通常程序。簡易判決不服→上訴至地方法院合議庭（第二審）。地方法院合議庭之判決，僅有**一次救濟機會**，不得再上訴第三審。此與通常程序可由地方法院→高等法院→最高法院之三級三審不同。
(B)	✗	同(A)之說明，簡易程序之第二審為地方法院合議庭，其判決即為終審，不得上訴最高法院。
(C)	✗	簡易程序之上訴限制，並非只限被告不得上訴，而是**任何人均不得**對地方法院合議庭之簡易判決第二審判決上訴第三審。
(D)	✓	簡易判決處刑之審級制度為**二級二審**：簡易庭（第一審）→地方法院合議庭（第二審）。地方法院合議庭之判決即為**終審判決**，不得再上訴第三審。依實務見解及刑訴§455-1之規定，簡易程序**僅有一次救濟機會**，檢察官不得上訴第三審。

[!NOTE]
重點整理

- 簡易判決處刑之審級：**二級二審**（簡易庭→地方法院合議庭），合議庭判決即為終審。
- 簡易程序不得上訴**第三審**，無論當事人為何人。
- 通常程序之搶奪罪雖非§376案件，得上訴第三審；但以簡易程序審理時，受簡易程序之審級限制。
- 簡易程序之適用前提：被告自白犯罪、法院認為宜以簡易判決處刑，且科刑以有期徒刑上限為限制。

陸、其他救濟程序（回復原狀等）

19、112年第49題（原第49題）

關於聲請回復原狀之敘述，下列何者最為正確？

(A) 非因過失，遲誤上訴期間者，於其原因消滅後20日內，得聲請回復原狀
(B) 非因過失，遲誤抗告期間者，於其原因消滅後10日內，得聲請回復原狀
(C) 非因過失，遲誤聲請撤銷檢察官命令之期間者，於其原因消滅後15日內，得聲請回復原狀
(D) 非因過失，遲誤告訴期間者，於其原因消滅後5日內，得聲請回復原狀

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	依刑訴§67 I，非因過失遲誤上訴期間者，於原因消滅後**5日內**得聲請回復原狀，非20日內。期限嚴格，以維護法的安定性。
(B)	✓	依刑訴§67 I，非因過失遲誤**上訴或抗告期間**者，得聲請回復原狀。依同條第2項，遲誤**抗告期間**之回復原狀聲請，應自原因消滅後**10日內**為之。
(C)	✗	回復原狀之對象限於**上訴及抗告期間**之遲誤（刑訴§67 I），不及於聲請撤銷檢察官命令之期間。15日亦非法定期限。
(D)	✗	回復原狀之適用範圍不及於**告訴期間**之遲誤。告訴期間為**實體**法上之期間限制，逾期不得告訴，無回復原狀之適用。

[!NOTE]
重點整理

- **回復原狀**（刑訴§67）：非因過失遲誤**上訴或抗告期間**者，得聲請回復原狀。
- 遲誤上訴期間→原因消滅後**5日內**聲請；遲誤抗告期間→原因消滅後**10日內**聲請。
- 回復原狀之適用範圍僅限上訴及抗告期間，**不及於告訴期間**或其他聲請期間。
- 須為**非因過失**遲誤，因過失遲誤者不得聲請回復原狀。

20、110年第60題（原第60題）

甲經高等法院判決論處強盜罪刑，甲不服提起上訴，最高法院因認甲並非依據卷內證據具體指摘原判決有何違背法令，而以上訴不合法定程式為由，判決駁回上訴確定。甲主張原確定判決不傳喚其聲請之有利證人乙到庭作證，且未敘明理由，致事實認定錯誤而影響判決結果。關於甲得請求救濟之途徑，下列敘述何者最為正確？

(A) 甲得向最高法院聲請再審
(B) 甲得向高等法院聲請停止刑罰之執行
(C) 甲得請求檢察總長提起非常上訴
(D) 甲得向高等法院聲明疑義

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明

(A) ✗ 最高法院以上訴不合法定程式駁回上訴，為**程序判決**，並未為實體判斷。再審須向**為實體確定判決之法院**聲請（刑訴§426 I）。最高法院係以程序理由駁回，非實體判決法院。實體確定判決為高等法院之判決，但甲所主張之事由（未傳喚證人、事實認定錯誤）屬原判決違背法令問題，非再審事由。

(B) ✗ 停止刑罰之執行須有法定事由（如再審開始之裁定等），甲僅主張原判決違法，無停止執行之法定依據。

(C) ✓ 甲主張原確定判決**未傳喚有利證人且未敘明理由**，此屬「應於審判期日調查之證據而未予調查」及「判決不載理由」之判決違背法令情形（刑訴§379⑩、⑭）。判決確定後發現**違背法令**，救濟途徑為**非常上訴**（刑訴§441），應由**檢察總長**向最高法院提起。甲本人不得逕行提起非常上訴，但得**請求檢察總長**提起。

(D) ✗ 聲明疑義（刑訴§483）係就**判決確定後之執行有疑義**者，向諭知該裁判之法院聲明之。本件非執行上之疑義，而係判決本身違背法令，不得以聲明疑義救濟。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **非常上訴**（刑訴§441）：判決確定後發現**違背法令**，由**檢察總長**向最高法院提起。
> - 當事人不得自行提起非常上訴，但得**請求檢察總長**提起。
> - 「應調查之證據未予調查」（§379⑩）及「判決不載理由」（§379⑭）屬判決違背法令。
> - 最高法院以程序理由駁回上訴（非實體判決），實體確定判決為下級審之判決。

21、114年第51題（原第51題）

> 甲與被害人發生衝突，因而與乙共同持棍毆傷被害人，被害人因不知乙之姓名，僅先對甲提起傷害罪之告訴，甲經檢察官起訴後，第一審審理中，檢察官另案查出乙之姓名，被害人於另案偵查中與乙達成和解，並撤回對乙之告訴後，甲始經法院判處傷害罪刑確定，甲知悉上情後，主張應依非常救濟程序，改諭知不受理判決。依實務見解，其主張有無理由？

(A) 無理由，因甲是正犯，且被害人未對甲撤回告訴，本應對甲論罪判刑
(B) 無理由，已經判刑確定，不可救濟
(C) 有理由，法院本應諭知公訴不受理，但應由甲聲請再審救濟
(D) 有理由，法院本應諭知公訴不受理，且應以非常上訴救濟

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	傷害罪為**告訴乃論之罪**（刑法§287），告訴之撤回依刑訴§239，對**共犯之一人**撤回告訴者，其效力**及於其他共犯**（告訴不可分原則）。被害人對乙撤回告訴，效力及於甲。法院本應對甲諭知公訴不受理。
(B)	✗	判刑確定後並非不可救濟。有非常上訴及再審等非常救濟程序。
(C)	✗	結論正確（法院本應諭知不受理），但救濟途徑有誤。本件為法院適用法律之錯誤（未適用告訴不可分原則而為不受理判決），屬判決**違背法令**，應以**非常上訴**救濟，而非再審。再審係針對事實認定之錯誤。
(D)	✓	依刑訴§239（告訴不可分原則），被害人對共犯乙撤回告訴，效力**及於共犯甲**。法院本應依刑訴§303②諭知**公訴不受理**判決。法院未適用告訴不可分原則而逕為有罪判決，屬**判決違背法令**，應以**非常上訴**救濟（刑訴§441），由檢察總長向最高法院提起。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **告訴不可分原則**（刑訴§239）：告訴乃論之罪，對**共犯之一人**告訴或撤回告訴，效力**及於其他共犯**。
> - 撤回告訴效力及於共犯→法院應諭知**公訴不受理**（刑訴§303②）。
> - 法院未適用告訴不可分原則而逕為有罪判決→**判決違背法令**→以**非常上訴**救濟。
> - 非常上訴 vs 再審之區分：違背法令→非常上訴；事實認定錯誤→再審。

附錄

一、年度出題分布

考點	108	109	110	111	112	113	114	合計
上訴期間與程式要件	—	1	—	3	1	—	—	**5**
上訴審級與範圍	1	—	1	3	2	—	—	**7**
抗告與再抗告	1	1	—	—	—	—	—	**2**

再審	—	1	—	1	—	—	1	**3**
簡易判決上訴	—	—	—	1	—	—	—	**1**
其他救濟程序	—	—	1	—	1	—	1	**3**
合計	**2**	**3**	**2**	**8**	**4**	**—**	**2**	**21**

> 113年無刑事訴訟法考古題 Markdown 檔案，故標示「—」。

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
上訴期間起算（判決送達）	在監被告應囑託監獄長官送達本人；多次送達以最先合法送達為準
送達代收人與在途期間	送達予代收人時即生效；住居所不在法院所在地應扣除在途期間
上訴書狀具體理由	通常程序上訴二審須具體理由；簡易判決上訴二審準用三審規定
辯護人代理上訴	辯護人為代理上訴，應以被告名義提起；配偶/法定代理人為獨立上訴
想像競合犯上訴三審	各罪名分別判斷是否得上訴三審；§376但書：一審無罪→二審改有罪得上訴
依職權逕送上訴	宣告死刑或無期徒刑者，法院應依職權逕送上訴（§344 V）
再抗告法定主義	再抗告以法律有特別規定者為限（§415 I）
再審管轄與停止執行	向原確定判決法院聲請；開始再審後得裁定停止刑罰執行
回復原狀	限於上訴及抗告期間之遲誤；上訴→5日內、抗告→10日內
非常上訴	判決確定後違背法令；由檢察總長向最高法院提起

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
代理上訴（辯護人）	獨立上訴（配偶/法定代理人）	代理上訴以被告名義提起；獨立上訴以自己名義提起
再審	非常上訴	再審→事實認定錯誤或新事證；非常上訴→判決違背法令
抗告	再抗告	抗告原則上得為之；再抗告以法律有明文規定者為限
通常程序上訴二審	簡易判決上訴二審	通常程序→上訴高等法院，得續上訴三審；簡易判決→上訴地方法院合議庭，不得上訴三審
上訴期間（上訴）	抗告期間（抗告）	上訴期間20日（§349）；抗告期間5日或10日
回復原狀（上訴遲誤）	回復原狀（抗告遲誤）	上訴→原因消滅後5日內聲請；抗告→原因消滅後10日內聲請
§376案件一二審均有罪	§376案件一審無罪二審改有罪	均有罪→不得上訴三審；一審無罪→二審改有罪→得上訴三審（但書例外）
沒收之從屬性	沒收之獨立性	§376本案不得上訴三審者，沒收部分亦不得獨立上訴三審

> 本文件整理自 108-114 年司律一試刑事訴訟法考古題，共 21 題，涵蓋上訴與救濟之核心考點。
> 最後更新：2026-02-20